

1501739-35.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj-sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501739-35.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2354780/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22212171 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 3117/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2354780 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

RAFAEL DE OLIVEIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP c/c Art. 40 "caput", VI e Art. 35 "caput" ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

17/03/2022

Réu Preso

Em 17 de março de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: a representante do Ministério Público, na pessoa da DRA. FABIANA MARIA NOVAES CANATELLI RODRIGUES, DDa. Promotora de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu RAFAEL DE OLIVEIRA, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Renato Saverio Souza Costa OAB 244018/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Juceil Batista Rodrigues (GCM) e Fernando Neves dos Santos (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal

de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Pelo defensor do réu foi requerido o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação das alegações finais por memorias, tendo em vista a juntada tardia do laudo pericial de fls. 155/159, trazido aos autos na data de hoje, às 12h:20min, o restou INDEFERIDO pela MM. Juíza de Direito tendo em vista que a análise do laudo não exigia complexidade e não haveria qualquer prejuízo à Defesa do acusado. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu RAFAEL DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos c.c. art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, eis que: 1) no mês de dezembro de 2021, nesta cidade e Comarca de Tatuí, associou-se à adolescente Bianca de Sousa Maia Fidencio para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas; e 2) no dia 30 de dezembro de 2021, por volta das 18h40, na rua Ezidio Vieira, nº 28, Jardim Rosa Garcia II, nesta cidade e Comarca de Tatuí, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com a adolescente Bianca de Sousa Maia Fidencio, trazia consigo, guardava e ocultava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 06 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 6,2 gramas, e 06 "tabletes" de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 6,8 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da denúncia, o acusado praticava tráfico de drogas, juntamente com a adolescente, sua namorada, fazendo entrega aos usuários que os procuravam. Para tanto, as drogas permaneciam com a adolescente, enquanto RAFAEL promovia a entrega aos interessados e a guarda de parte da renda auferida. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina quando receberam informação de que um casal estava praticando o comércio ilegal. Os agentes públicos se dirigiram ao endereço e avistaram o acusado e a adolescente, os quais, ao notarem aproximação da viatura, tentaram dissimular e saíram caminhando. Houve a abordagem, oportunidade em que Bianca arremessou um maço de cigarros e uma camiseta para dentro de um bar. RAFAEL, por sua vez, rasgou notas de dinheiro que estavam em seu poder e resistiu à abordagem, sendo necessário o emprego de força moderada para contê-lo. Os itens arremessados por Bianca foram localizados, constatando-se conter, dentro do maço, 06 "tabletes" de "maconha" e 06 porções de cocaína. Em revista pessoal, com RAFAEL foram encontrados R\$ 126,00. Em seguida, a adolescente retirou R\$ 337,00 das vestes íntimas e entregou aos Guardas. O réu foi notificado (fls. 114) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 123/125). Assim, por decisão proferida no dia 14 de fevereiro de 2022, foi recebida a denúncia (fls. 126/128). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, ultimando-se com o interrogatório do réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição do acusado, sustentando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 27, bem como Certidões a fls. 28/38. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido ministerial comporta parcial procedência, absolvendo-se o réu da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de

drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei:" (grifos aditados). No entanto, para se que não se confunda o mero concurso de pessoas – de que trata o art. 29 do Código Penal – com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro, denotando vínculo associativo e não mero concurso eventual. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes. (...)” (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). Além disto, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...)” (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014). Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: "(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...)” (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103). Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, embora haja comprovação de que o acusado e a adolescente exerciam o tráfico de entorpecentes, inexistem provas suficientes de que praticavam ou pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente. Isto porque não houve prévia investigação policial, onde fosse possível verificar que o tráfico não seria exercido pontualmente, tampouco foram localizados instrumentos de preparação ou anotações de contabilidade, revelando o caráter não episódico da traficância. Portanto, diante da ausência de provas em relação ao animus associativo entre o réu e a adolescente, imperiosa a absolvição deles no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), pelo auto de constatação preliminar (fls. 11), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 155/159) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 05), manteve-se silente. Em juízo, no dia dos fatos estava voltando para casa com Bianca quando foi enquadrado pelos policiais. Quando eles tocaram Bianca, ao invés de chamar uma policial feminina, ele ficou alterado. Nem sabe quanto tinha com a Bianca, estava bêbada. A droga não era sua, não sabe nem como apareceu. Não tem como eles ouvirem falar dele, pois, não estava mais mexendo com droga. Não conhece os guardas municipais. Não admitiu a propriedade de droga nenhuma, essa droga foi imputada a ele. O réu ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, negou por completo a prática delitiva, imputando aos agentes de segurança a situação de flagrante

forjado, eis que nem a droga existia, quer dele, quer de sua namorada Bianca, nem a quantia de R\$126,00 estava em seu poder. Ocorre que a versão do réu restou isolada das demais provas acostadas aos autos. Vejamos. De outro lado, o Guarda Civil Municipal Fernando Neves dos Santos, em sede policial (fls. 14), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam de serviço em patrulhamento pelo bairro Rosa Garcia II, quando um morador, que preferiu não se identificar, relatou a equipe que, pela Rua Ezídio Vieira, um casal estava traficando entorpecentes. Em posse dessas informações, se deslocaram até o endereço citado e, ao chegarem no local, avistaram o casal, que, ao perceber a aproximação da viatura, saiu andando. Então, foram abordá-los e Bianca lançou um maço de cigarro e uma camiseta para dentro de um "bar" que estava com a porta aberta. O acusado não queria ser abordado e foi necessário o uso de força moderada para contê-lo. O réu chegou a rasgar cédulas de dinheiro que estavam em seu bolso. Ele foi imobilizado, sendo necessário o uso algemas. Ao verificar o que Bianca havia lançado para dentro do estabelecimento, encontrou dentro do maço de cigarro, 06 porções de maconha e 06 porções de cocaína, tipo Aricanduva. RAFAEL estava na posse de R\$ 126,00. Ao colocarem o acusado no compartimento de preso, o réu veio a gritar, incitando moradores do bairro contra a equipe, bem como veio a desferir chutes no compartimento de preso da viatura, chegando a danificar o revestimento de plástico. Indagado, RAFAEL confessou a mercância e, indagada, Bianca relatou que é namorada de RAFAEL. Todos os entorpecentes encontrados pertenciam a RAFAEL. Com o apoio da GCMF Ednéia, a adolescente infratora retirou do sutiã a quantia de R\$ 337,00. Em juízo, a testemunha disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Rosa Garcia, quando uma pessoa os abordou e relatou que um casal estava realizando a venda de entorpecentes na rua Ezídio Vieira. Foram ao local apontando e identificaram o casal. Com a aproximação o casal saiu andando. A adolescente no momento da abordagem lançou um maço de cigarro e uma camiseta para dentro de um bar. O réu resistiu a abordagem, sendo necessário algemá-lo. No maço que foi jogado pela adolescente encontraram 06 porções de maconha e 06 porções de cocaína, tipo Aricanduva. Com o indivíduo do sexo masculino encontraram a quantia de R\$ 126,00. O réu desferiu chutes na viatura e incitou moradores. Com a ré foi encontrada quantia em dinheiro. O réu admitiu a totalidade da droga. Já era conhecido dos meios policiais como suspeito de envolvimento no tráfico. Convergindo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Juceil Batista Rodrigues, em sede policial (fls. 03), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Em juízo, disse que um morador do bairro relatou que um casal estava fazendo o tráfico e deu a localização. Foram ao local apontando, visualizaram o casal e com a aproximação eles começaram a andar. A moça tinha uma camiseta nas mãos e dispensou algo para o interior do bar, que depois verificaram tratar-se de um maço de cigarro com seis porções de maconha e seis porções de cocaína do tipo Aricanduva. Com a chegada da GCM feminina a adolescente foi revistada e encontrado dinheiro em seu poder. No trajeto para a delegacia o réu chutou a viatura, gerando dano ao automóvel. O dinheiro encontrado em poder de Bianca era do irmão dela e não sabe porque estava com ela. Ele tinha apenas R\$6,00, não tinha mais do que isso. Estava trabalhando como servente. Ganhava cerca de R\$85,00 por dia. Não tem filhos. Já foi processado. Estava em livramento condicional. Perguntas da acusação – esse outro valor que os policiais dizem que estava com ele, deve ser do dinheiro de maconha. Não viu como os policiais plantaram a droga, pois ficou com a cara na parede quando foi abordado. Seu patrão é o Ciro. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu

Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à

elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Quanto às declarações de Ciro e da adolescente Bianca de fls. 148/154, tem-se que esses não têm valor probatório pleno, pois produzidos sem o contraditório ministerial. É dizer, as declarações foram produzidas sem oferta de oportunidade à parte acusadora de formular perguntas a essas pessoas e participar de sua oitiva, eis que as testemunhas foram arroladas fora do prazo legal e a prova declarada preclusa, conforme decisão de fls. 142. E, portanto, não há como se conferir valor probatório a versões de pessoas que não foram submetidas ao crivo do contraditório judicial. Até porque não foram arroladas oportunamente como testemunhas e não há nenhum elemento probatório que robusteça a versão dessas pessoas. Como se vê, pela inverossimilhança e imprecisão dos relatos de Bianca e Ciro, aliada à sua produção de forma unilateral, tem-se que esses elementos não tem o condão de afastar o sólido conjunto probatório produzido nos autos, através do qual se nota a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão das drogas onde a adolescente as dispensou; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 155/159), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações, forma de acondicionamento própria para a venda "a varejo" de entorpecentes; 3) a conduta do acusado e da adolescente, os quais, ao avistarem a viatura, apresentaram comportamento suspeito, consistente em dispensar drogas; 4) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; 5) a localização do acusado e da adolescente nas mesmas condições da delação apócrifa descrescia; e 6) a informação dos guardas de que, informalmente, o acusado confessou a prática do tráfico de drogas. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma

substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal

mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, aprendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96). Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 155/159) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo–, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. De fato, observo que o acusado ostenta duas condenações criminais definitivas, de modo que utilizarei uma delas (Proc. 0002331-38.2014.8.26.0624 – fls. 29) como Maus Antecedentes, e a outra como agravante de reincidência, sem que se incorra em bis in idem. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do E. TJSP: “é plenamente viável o rateio das duas condenações definitivas do réu João entre antecedentes e reincidência, sem incidir em bis in idem, permitindo a correta individualização de sua pena, de acordo com todas as circunstâncias do caso concreto.” (TJSP; Apelação Criminal 1500174-20.2021.8.26.0544; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021). De igual modo, entende o C. STJ (“É firme o entendimento desta Corte Superior de que, em se tratando de agente

que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes" - HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018). Por tal razão, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é de rigor, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase, presente a agravante de reincidência, (Proc. nº 0011606-40.2016.8.26.0624, fls. 30), agravo sua pena na fração de 1/6, gerando a reprimenda legal de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Cabe ressaltar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Finalmente, considerando que o crime foi praticado com o envolvimento adolescente, tem-se por necessária a incidência da causa de aumento de que trata o art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas. E, portanto, aumento sua pena em 1/6, gerando a reprimenda legal de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, tratando-se de réu reincidente e de maus antecedentes, resta inviabilizada a concessão da benesse em questão. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fulcro no artigo 33, § 2º, a, do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando a quantidade de pena aplicada. As mesmas motivações acima expostas impedem a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu RAFAEL DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão em regime inicial fechado e 793 (setecentos e noventa e três) dias multa, com valor unitário no mínimo legal; e 2) absolver o acusado da imputação de prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no

art. 386, inciso VII, do Código de Processo

Penal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar do acusado. E mais, considerando os maus antecedentes e a reincidência específica do acusado, evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. E não se venha alegar a situação de calamidade pública decorrente da doença COVID 19, gerada pela infecção do vírus sars-cov-2 ("coronavírus"). Trata-se de tema que reclama prudência judicial no exame das medidas cautelares pessoais, em especial, as prisões preventivas e temporárias. Isso porque, se é fato que as aglomerações de pessoas podem acelerar o contágio da doença e sua disseminação, também é verdade que a libertação indiscriminada dos presos, além de implicar indiscutível prejuízo à manutenção da segurança pública e da aplicação da lei penal (já que há o indiscutível risco de, em tese, praticar novos delitos ou por-se em fuga), também poderá propiciar, por esse fluxo acentuado de pessoas, maior transmissão da enfermidade. É dizer, pode ser que o preso, agora libertado, já esteja infectado, mas em quadro assintomático (o que, segundo dados científicos, pode demorar até 2 semanas ou nem mesmo se manifestar), o que proporcionará a infecção de seus familiares e outras pessoas com quem tiver contato. Outrossim, em estabelecimentos prisionais, onde o acesso de pessoas é controlado e, por ora, proibido, há menor probabilidade ser contaminado do que, em liberdade, saindo as ruas, onde não se tem controle sob a mobilidade dos cidadãos. Dito de outro modo, se a intenção é preservar a saúde do preso, é possível que, em liberdade, por não haver restrição e/ou controle de sua mobilidade, tenha maior possibilidade de contrair a doença do que preso, onde o acesso de pessoas é restrito e, por ora, proibido. O que se quer dizer, em síntese, é que a alegação de pandemia não conduz, invariavelmente, a soltura do preso. Devem ser analisados outras peculiaridades do caso concreto. In casu, os elementos acima apontados denotam que é o caso de manutenção da prisão preventiva, o que não se altera com a situação de calamidade pública gerada pelo coronavírus. Até porque não se tem notícia de preso infectado na unidade prisional do acusado, que esse se encontra enfermo, tampouco que integra grupo de risco. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Diante da condenação, fica ainda obrigado o réu a recolher custas de 100 (cem) UFESP's, na forma do art.4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Não lhe concedi os benefícios da Justiça Gratuita, pois o réu constituiu advogado (fls. 119), signo presuntivo de riqueza que revela a capacidade dele para suportar o ônus financeiro das custas processuais. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor referente às custas processuais e o total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art.91, II, "b", do Código Penal, c.c. art.63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do bem apreendido (R\$ 463,00 em dinheiro - fls. 10), pois comprovada sua proveniência criminoso, em favor da união, apropriados ao Funad (§1º do referido art.63). Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA